

1501316-03.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ATOS INFRACIONAIS COMO INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NOVA ORIENTAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE AS DATAS DOS ATOS INFRACIONAIS E O CRIME IMPUTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501316-03.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501316-03.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013698/2022 - 20º D.P. AGUA FRIA, 22467016 - 20º D.P. AGUA FRIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CAIO DOS SANTOS NOGUEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

ERICK PEREIRA ROQUE e CAIO DOS SANTOS NOGUEIRA, qualificado nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de janeiro de 2022, na Rua Boi Pigua, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportavam/traziam consigo/guardavam, para evidentes fins de tráfico ilícito de drogas, 11 porções de maconha; 32 porções de cocaína e quatro pinos de cocaína; 108 porções de maconha, 31 pinos de cocaína, 48 tubos de skank descritos conforme auto de exibição/apreensão de fls. 17, laudo de constatação de fls. 34/38 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a ser oportunamente juntado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância. Segundo se apurou, policiais militares dirigiram-se à comunidade da Vila Albertina e, ao adentrarem pela Rua Boi Pigua, constataram que Erick e Caio estavam

sentados num degrau. Ao notarem a aproximação dos policiais, empreenderam fuga, mas, acabaram sendo detidos (fls.07 e fls.08). Durante revista, os policiais encontraram, dentro da bermuda de CAIO, trinta e dois papérolas e quatro pinos de cocaína, bem como a quantia de trinta e oito reais em dinheiro. Já com ERICK, encontraram, no interior de sua bermuda, onze invólucros contendo maconha e a quantia de vinte e dois reais em dinheiro.

Em seguida, os policiais seguiram no local em companhia de um cão policial, o qual indicou que havia drogas no interior de um quadro de energia, aproximadamente cinco metros do local da abordagem. No referido quadro, os policiais localizaram uma sacola plástica contendo em seu interior cento e oito porções de maconha, trinta e uma porções de cocaína, quarenta e oito tubos de skunk e a quantia de quinze reais em dinheiro. Os pinos de cocaína e algumas porções de maconha estavam embaladas de forma idêntica àquelas encontradas com CAIO e ERICK. Diante disso foram presos em flagrante.

Os réus foram notificados e apresentaram Defesa Preliminar, sendo recebida a denúncia e efetivada a citação, designando-se audiência na qual ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, e foram realizados os interrogatórios. Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, em relação às testemunhas Fabiana, Mariana e Jeniffer, a instauração de procedimento para apuração de falso testemunho. Quanto a Erick, em virtude de sua reincidência, postulou majoração da pena, não incidência do redutor e fixação do regime inicial fechado para cumprimento, argumentando, ainda, que a quantidade e variedade de drogas impedem o benefício para os dois acusados.

A Defesa constituída dos acusados pediu a sua absolvição com base no art. 386, incisos II, IV, V e VII, do CPP, argumentando, em síntese, que trouxe testemunhas que disseram não ter sido encontradas drogas com os réus e que somente os policiais foram ouvidos, e não teriam arrolado outras pessoas no local que viram o ocorrido. É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17, pelo Laudo de Constatação de fls. 34 e químico-toxicológico de fls. 176/78. A autoria é certa.

Silentes na fase policial (fls. 12/13), judicialmente, os réus foram interrogados. O corréu Erick disse que mora na Rua Boi Pingua e viu Caio descendo. Chegaram os policiais e o cachorro achou drogas no buraco. Não tinha nada, nem dinheiro, Caio tinha 40 reais para cortar o cabelo. Não conhecia os policiais anteriormente. Um moleque correu, a droga da caixa de luz não era deles. Os fatos ocorreram 9 horas da manhã. Quando os policiais chegaram, estavam separados. É ajudante de pintor, pedreiro. Mora com seus pais e sua filha, de 17 anos. Estava em regime aberto. Foi condenado por roubo e furto.

O acusado Caio afirmou encontrou Erick, parou do lado dele, tinham acabado de se encontrar. Dois policiais os enquadraram e revistaram, nada foi localizado. Chegaram mais quatro policiais e um cachorro na caixa de luz, onde encontrou drogas. Os policiais disseram que a droga era deles. Tinha 40 reais para cortar o cabelo. Negou que a droga fosse deles. Nunca tinha sido preso como maior de idade. As três passagens foram como usuário pela Vara da Infância (fls. 55). Fez tratamento no Capes. Trabalhava no lava rápido de seu pai. Mora na Rua Dr Floriano Paulo de Almeida, perto dessa da abordagem. Não conhecia os policiais anteriormente. Morava com seus pais. Não tem filhos. Tinha outras pessoas em um barzinho.

A testemunha Henrique, policial militar, reconheceu os réus em audiência. Era uma operação no local e tinham conhecimento de tráfico ali. Viu os dois sentados e deteve Erick, o outro policial prendeu o corréu. Com Erick havia cocaína na bermuda e dinheiro em notas picadas. O policial Ruiz fez a mesma coisa com o outro abordado. O cão farejador encontrou um buraco no quadro de luz com embalagens de drogas. Foi dada voz de prisão. Eles não tinham lesões. Caio tinha outras 3 ocorrências na mesma rua, 2019, 20 e 21. Disseram que era para o uso a droga encontrada. A rua é bem curta, 150 a 200 metros, só estavam os dois e não havia

mais ninguém. Erick tinha 30 papelotes e 30 pinos azuis. Os dois tinham dinheiro picado. A distância da caixa de energia era de 3 a 5 metros. Correram poucos metros e foram detidos. A caixa de luz estava do lado direito. O Batalhão ainda não dispõe de câmeras. Foi até a residência de Erick pegar o documento, a 150 metros do local da abordagem. O réu mora em outra viela, não na da abordagem. Eles estavam sentados a 150 metros da casa de Erick, ele tinha cerca de 30 reais (notas de 5 e 2). No quadro havia papelotes, pinos azuis e maconha em papel filme, há registro fotográfico. Não havia mais ninguém no momento da abordagem. As embalagens do quadro de luz eram da mesma forma que a droga encontrada com Erick. Com Caio também, da mesma forma. A droga do quadro de luz era negaram a propriedade. Não conhecia os acusados, nunca tinha ido nesta via antes.

A testemunha Rodrigo, policial militar, reconheceu os réus em audiência. Desembarcaram na viela e viram os dois sentados, e eles tentaram fugir. Vistoriou Caio, no bolso direito da bermuda, havia 11 maconha e no bolso esquerdo 22 reais. O cão farejador (pelo odor) encontrou atrás do quadro de luz, dentro de uma sacola preta, 9 pedaços maiores de maconha, 98 invólucros de maconha, 31 de cocaína e 15 reais. ERICK foi revistado pelo outro policial, Guedes. Não se recorda do que ele encontrou. Eles disseram desconhecer a mochila e da droga disseram que eram usuários. O local é ponto de venda de drogas. Na hora da abordagem, não havia outras pessoas. Havia casas nas duas paredes. Eles estavam em um degrau da viela. Erick não disse que morava lá, não era endereço dele. Havia algo com Erick, mas o outro policial que encontrou. A abordagem foi por volta de 9 ou 10 horas da manhã. É uma comunidade, uma viela que liga uma rua à outra. Só os dois estavam na viela. Os acusados mostraram nervosismo. O Batalhão não dispõe de câmeras. Não conhecia os acusados.

A testemunha de defesa de Caio, Fabiana, disse que viu o réu ser abordado, ela estava saindo para fazer uma faxina. Viu uma terceira pessoa correndo, que não os réus. Não viu ser localizada droga com Caio e nem com o corréu. A droga foi achada em um quadro de luz, distante cerca de 5 metros dos acusados. Estava a 15 metros deles e nada ouviu. Erick estava sentado na porta da casa dele, a 15 metros de Caio. Viu a viatura descendo. Os meninos ficaram parados ao ver a viatura. Havia muitas pessoas ali na viela, o local tem 50 metros. É uma passagem. Viu os dois serem abordados. Só os dois foram revistados. Viu o momento em que trouxeram o cachorro e ele encontrou as drogas. Conhece os réus de vista. Não foi na delegacia porque estava indo trabalhar. O cachorro que encontrou as drogas na caixa de luz. Manteve o depoimento mesmo sendo advertida de que poderia ser processada por falso testemunho.

A testemunha de defesa de Caio, Edgar, afirmou que o réu Caio trabalha com ele, tem um terreno de invasão e fica uma pessoa tomando conta do terreno, o réu limpa e varre esse terreno. Paga de 500 a 700 reais. O acusado é filho da testemunha, mora com ele. O réu trabalha cerca de 8 horas por dia.

A testemunha de defesa Mariana disse que conhece os dois acusados. Ia levar a filha na casa da sogra, viu um menino correr. Caio estava descendo e Erick na porta da casa dele. Os policiais foram diretamente nos réus. Caio tinha cerca de 40 reais, ele disse que estava indo cortar o cabelo. Com eles não havia droga, mas, encontraram drogas em uma caixa de luz, a 12 metros de onde eles estavam. Tinham muitas pessoas no local. Os policiais impediram a passagem das pessoas. Viu o momento em que eles foram revistados, ela estava a 5 metros deles. Estavam a cerca de 4 metros um do outro. O cachorro encontrou droga na caixa de luz. Viu Jeniffer. Sua sogra mora perto dali. Acha que eles não são amigos. Nunca soube do envolvimento deles com crimes. Foi advertida e manteve seu depoimento.

A testemunha de defesa de Caio, Jeniffer, conhece os dois acusados de vista. Estava levando seu filho, viu Caio descendo e Erick sentado. A polícia chegou e foi direto nos dois. Um rapaz correu, não sabe quem é. Havia outras pessoas, é uma descida, tem dois becos, tem de 30 a 50 metros. O cachorro encontrou as drogas em um buraco. A droga estava a 20 metros dos réus. Caio tinha dinheiro, cerca de 20 reais, acha que ele disse que ia cortar o cabelo. Nada havia com Erick, acha que ele era morador dali. Estavam distantes um do outro cerca de 10 metros. Na viela tinha muita gente. Acima e abaixo da caixa de luz. Tinham dois bares ali. Sempre

vê Caio trabalhando, o pai dele tem um lava rápido. Não pôde passar pelo local, nem ela e nem Mariana, tiveram que ficar esperando. Manteve o depoimento, mesmo advertida das penas do falso testemunho.

Desta forma, a prova acusatória autoriza a condenação nos termos da denuncia. Os policiais foram seguros em seus relatos, imputando aos réus a posse de drogas diversas, depois de tentarem fugir ao notar a aproximação policial. Não só encontraram drogas diversas e dinheiro trocado com eles, como, a uma curtíssima distância, foram achadas mais drogas escondidas no quadro de luz, só localizadas com a ajuda do cão farejador. E o mais importante, como usuários, não estariam com drogas diversas, em grande quantidade, em embalagens idênticas às que estavam dentro do quadro de luz. Eram, pois, os traficantes.

Cabe ressaltar que eles gozam de presunção, "Juris tantum" de veracidade em tudo quanto alegarem, não logrando a defesa produzir qualquer prova que colocasse seus relatos em descrédito. Os policiais nem conheciam os acusados e não tinham motivos para prejudicá-los. Se é verdade, como disseram as testemunhas de defesa, que muitas pessoas estavam ali, por qual motivo somente os dois réus, que nem juntos estavam, seriam os únicos abordados e incriminados? Por que não foram abordados os tantos ocupantes dos dois bares que as testemunhas de defesa afirmaram estar ali no momento? Por qual motivo nenhuma destas testemunhas foi à delegacia após o ocorrido, para explicar que dois inocentes estavam sendo injustamente prejudicados? Só se pode concluir que as testemunhas Fabiana, Mariana e Jeniffer, com a qualificação enviada na data de hoje para o chat da audiência, não disseram a verdade. Mesmo advertidas, continuaram negando a apreensão da droga com os acusados. Anote-se, ainda, que, obviamente, os policiais não teriam deixado a revista ser feita com a proximidade de testemunhas, sempre é mantida uma distância de segurança.

A quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como o contexto do flagrante impedem a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, nos termos do §2º do mesmo artigo da Lei 11.343/06.

3- Passo à dosagem das penas.

Serão aplicadas as penas mínimas de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, já que a quantidade e natureza das drogas não permitem a fixação acima do mínimo.

Diante da reincidência comprovada (25ª Vara Criminal- vide certidão de fls. 59), agravo as penas de Erick em um sexto, com fulcro no artigo 61, inciso I do Código Penal, chegando-se ao montante de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo legal. O corréu Caio é primário, mas tem 3 processos por ato infracional e dois processo junto à 2ª Vara Criminal de Santana por uso de drogas, um também por desacato. A sua menoridade não pode diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, para Erick, pelo mesmo motivo afasto a incidência do § 4º, do artigo 33. E nem se diga tratar-se de bis in idem, pois assim já se decidiu em casos análogos:

"Constatando-se a ocorrência da reincidência, ausente ilegalidade na não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista o não preenchimento de exigência determinada nesta regra, qual seja, ser o agente primário. 2. Não há o que se falar em bis in idem, mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico - a reincidência - quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente" (HC 242769/SP - Ministro Jorge Mussi -f DJ 21.09.2012).9 (g.n.).

Para o corréu Caio, impossível o reconhecimento do redutor, diante das passagens criminais citadas. Assim se assentou a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ATOS INFRACIONAIS COMO INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NOVA ORIENTAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE AS DATAS DOS ATOS

INFRACIONAIS E O CRIME IMPUTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão é claro no ponto em que adota a tese prevalente na Sexta Turma, segundo a qual, mesmo considerando a nova compreensão desta Corte Superior, a possibilidade do afastamento da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não incide no caso, porquanto o crime em consideração foi praticado em 4/1/2019, e o embargado, conforme certidão encartada nos autos, respondeu por dois atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas em 23/8/2015 e 7/10/2016, e um ato infracional análogo ao crime de portar droga para o consumo próprio, em 14/9/2016, ou seja, em período que o órgão colegiado considerou extenso. Ademais, não há, pelas circunstâncias apontadas, gravidade concreta que justifique o afastamento do redutor de pena. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1881115/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

As penas privativas de liberdade devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado, nos termos do que propõe a Lei n.º 11.464/07, em seu art. 2º, §1º. O tráfico é um crime grave, refere-se a delitos contra o patrimônio e ao tráfico de armas. A reincidência de Erick impede também o benefício, e, em regime aberto desde o final do ano passado, voltou a praticar crimes.

Deixo de reconhecer a detração em face à notória inconstitucionalidade do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A recente Lei nº 12.736/12, de duvidosa constitucionalidade, fere notoriamente diversos princípios consagrados na Carta Magna. Atenta contra a individualização da pena, na etapa executória, contra o Princípio do Juiz Natural, e contra a isonomia, ao tratar condenados iguais (com mesmas penas pela prática dos mesmos delitos) de forma desigual. Com efeito, o anseio pelo esvaziamento das superlotadas prisões ou a lentidão do aparato judiciário no que tange ao julgamento dos pleitos progressivos não autorizam procedimentos à míngua da Lei Maior, criados sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que terá de conviver com criminosos precocemente soltos.

Não poderão recorrer em liberdade, justificando-se a custódia preventiva como garantia de aplicação da lei penal, evitando-se o risco de fuga após condenação em regime mais gravoso. Outrossim, no caso de Erick, a reiteração impõe a manutenção da prisão.

Recomendem-se na prisão em que se encontram.

4. Ante exposto, julgo procedente a ação penal para condenar ERICK PEREIRA ROQUE e CAIO DOS SANTOS NOGUEIRA, já qualificados nos autos, às respectivas penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo legal, o primeiro, e 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no piso legal, o segundo, como incursos no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

Atenda-se ao requerimento da representante do Ministério Público no tocante às testemunhas de defesa mencionadas.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA